

1500333-04.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038089/2022 - 01º D.P. SUZANO, 22923412 - 01º

D.P. SUZANO, 61/22/320 - 01º D.P. SUZANO, 2038089 - 01º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alice Mota e outro

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500333-04.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500333-04.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038089/2022 - 01º D.P. SUZANO, 22923412 - 01º

D.P. SUZANO, 61/22/320 - 01º D.P. SUZANO, 2038089 - 01º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alice Mota e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de ALICE MOTA (nascida em 20/09/2003) e GEOVANE DA SILVA MOREIRA (nascido em 10/07/1993), devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, pois, em 09/02/2022, por volta das 15h20, na Rua Santa Júlia, altura do nº 142, Vila Fátima, neste Município e Comarca de Suzano, trariam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 46 porções de maconha (130,64g),

25 porções de cocaína (17,75g) e 65 porções de crack (13,65g), além de R\$ 40,00 em espécie.

Em 10/02/2022, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 47/49).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias às fls. 132/135 e 137/142.

Em 27/04/2022, foi recebida a denúncia e concedida a liberdade provisória aos Réus, com cautelares alternativas (fls. 160/161).

Em 25/07/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, em que foram ouvidas testemunhas e interrogados os Réus, sendo declarada encerrada a instrução (fls. 231/232).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 236/242).

A Defesa da Ré Alice, em seus memoriais, alega, preliminarmente, a nulidade da perícia realizada nas drogas apreendidas, por ter sido feita apenas em amostra e não na totalidade dos entorpecentes e sem a nomeação de advogado para a Ré, não sendo sequer possível requerer perícia na amostra guardada como contraprova; e a nulidade das provas, eis que não teria sido concedido o direito ao silêncio à Ré e as alegações dela teriam sido forjadas em delegacia. No mérito, requer a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06 ou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal (fls. 244/252).

Já a Defesa do Réu Geovane, em suas alegações finais, requer, preliminarmente, a anulação das provas, por ter a abordagem sido realizada por guardas civis municipais que estariam em patrulhamento ostensivo de rotina, em atividade típica das forças de segurança pública, fora de sua atribuição constitucional e legal, não havendo, também, situação flagrancial que autorizasse a prisão por qualquer pessoa do povo. No mérito, requer a absolvição, por falta de prova de autoria.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 (fls. 255/278).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 15/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 18/21) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 101/103), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A alegação da Defesa da Ré Alice de nulidade da perícia realizada nas drogas deve ser rejeitada. Não há amparo legal para que todos os entorpecentes sejam periciados, sendo lícita a perícia de pequena amostra, para constatar se as substâncias apreendidas são ou não entorpecentes. Seria impossível periciar toda a droga, justamente porque não sobraria nada para contraprova – o que a própria Defesa expressamente não requer –, além de ser inviável que todos os entorpecentes apreendidos no Brasil sejam levados aos institutos de criminalística, com perícias que demorariam anos e gastos públicos inúteis.

Ademais, o fato do laudo pericial definitivo ter sido concluído antes da nomeação de defensor dativo à Ré também não é causa de nulidade, eis que, depois, poderia a Defesa, tempestivamente e com algum fundamento, ter impugnado o laudo, o que não fez, não havendo qualquer motivo para duvidar da lisura do laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística, como faz a Defesa da Ré Alice.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O guarda civil municipal Fábio Correa declarou que estava em patrulhamento de rotina, pelo bairro da Vila Fátima. Foram abordados por um munícipe, que relatou que havia visto uma movimentação no matagal. O local já era conhecido como ponto de compra e venda de drogas, por isso foram averiguar. Chegando lá, viram duas

pessoas, um homem e uma mulher, que, ao verem a chegada da equipe, fugiram. O homem dispensou uma caixa, na fuga. Conseguiram abordar os dois, sendo eles os Réus. Pediram para a Ré tirar o que tivesse do bolso, mas ela não trazia nada consigo. Já o Réu foi revistado, sendo encontrados cerca de R\$ 400,00 em notas miúdas. Voltaram ao local onde viram os Réus inicialmente e encontraram a caixa dispensada pelo Réu, em que havia porções de crack, cocaína e maconha. Indagados, ambos confessaram a traficância, sendo os dois levados à delegacia. Não os conhecia e nem tem nada contra os Réus. Não era possível ver os Réus do local em que foi feita a denúncia pelo munícipe. Foi necessário ir ao local averiguar. Só viu os Réus no local. Leram os direitos dos Réus após indagarem o que eles faziam.

O guarda civil municipal Matheus Felipe Ribeiro de Sousa prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório judicial, o Réu Geovane disse ter 29 anos, ser divorciado, não ter filhos, ser vendedor e ter o 2º grau completo. Negou a prática do crime. Disse que foi ao local comprar drogas, juntamente com a Ré Alice. O traficante se assustou, dispensou uma caixa e correu, se evadindo. A Ré era sua mulher à época dos fatos. Compraria porções de maconha para uso própria. Estava com os R\$ 400,00 em espécie, proveniente do seu trabalho. Não disse nada aos guardas, que já concluíram que ele era o traficante, por estar com dinheiro. Em delegacia, diz ter negado a autoria do crime. Não leu o interrogatório em delegacia. Não conhecia o delegado ou o investigador. Não foi advertido sobre o direito ao silêncio. Nunca traficou na vida. Em delegacia, confessou a traficância em conjunto com a Ré, sua companheira (fls. 12).

Em seu interrogatório judicial, a Ré Alice disse ter 18 anos, ser solteira, não ter filhos, ter cursado até o 1º ano do ensino médio e ser babá. Negou a prática do crime, dando a mesma versão que o Réu Geovane em interrogatório judicial.

Acrecentou que trazia R\$ 10,00 nas mãos, que dispensou na fuga, que seriam usados para comprar maconha para uso próprio. Disse aos guardas que fora ao local comprar maconha e que correu porque se assustou. Negou ter sido interrogada em delegacia. Não conhecia o delegado, nem o escrivão. O Réu estava com dinheiro, cuja origem desconhece, pois trabalhavam como seguranças em uma tabacaria, acreditando que ele “pegou dinheiro adiantado com uma mulher”. Depois, disse que o Réu também vendia peixe, mas o dinheiro não era proveniente das vendas. Nunca viu o Réu envolvido com nada de errado. Não foram agredidos física ou verbalmente pelos guardas. Não foi advertida sobre o direito ao silêncio. Em delegacia, confessou a traficância em conjunto com o Réu, seu companheiro (fls. 12).

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, traziam consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Não há que se falar em ilegalidade da atuação de guardas municipais na prisão em flagrante dos Réus, visto que esses presenciaram conduta suspeita – a fuga dos Réus, com a dispensa de uma caixa –, em local conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, e abordaram os Réus em via pública, em estado flagrancial, como qualquer pessoa do povo poderia fazer, não atuando como força de segurança pública, portanto. Nesse sentido, precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia

investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante. (...)" (STJ, AgRg no HC 703036/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08/03/2022)

Da mesma forma, não há qualquer nulidade das provas pelos Réus não terem sido advertidos a respeito do direito ao silêncio. Essa advertência é necessária única e exclusivamente nos interrogatórios policial e judicial, não em conversas informais com pessoas responsáveis pela prisão em flagrante, sendo que o relatado a essas pessoas tem baixo valor probatório, podendo ser contradito nos interrogatórios. Ainda que assim não fosse, a ausência dessa advertência poderia apenas e tão somente afastar a licitude das versões informalmente passadas às testemunhas, não a integralidade dos depoimentos dessas, tampouco os interrogatórios policial e judicial, em que houve essa advertência expressa.

Os depoimentos das testemunhas em juízo, aliados aos interrogatórios em sede policial, bem demonstram a autoria do crime de tráfico de drogas por ambos os Réus. Os guardas são claros em apontar que havia apenas os Réus no local dos fatos, tendo o Réu dispensado a caixa com as drogas e sido preso na posse de dinheiro, ao lado da Ré, sua companheira, tendo ambos confessado em delegacia que estavam traficando, inclusive informando detalhes sobre a forma como o crime fora cometido por eles. As negativas em juízo são frágeis, notadamente porque há divergência entre os Réus sobre a origem do dinheiro apreendido. O Réu diz que é proveniente da venda de peixes, mencionando, no início do interrogatório, ser vendedor. Já a Ré diz que eles trabalhavam como seguranças em uma adega e que esse dinheiro, segundo o que o Réu a informou, seria um adiantamento pelos serviços, não pela venda de peixes. Ademais, não foi apontado qualquer motivo para que a Autoridade Policial falseasse interrogatórios, o que seria crime, sendo impossível que o delegado soubesse que os Réus eram companheiros se não tivessem informado esse fato em delegacia, o que mostra que a verdade foi dita em delegacia de polícia, tentando os Réus se isentarem de responsabilidade penal ao negarem a autoria delitiva em juízo. O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois nada há nos autos que indique que as drogas apreendidas se destinavam a consumo próprio pelos Réus, não tendo nem mesmo eles, em nenhum momento, apresentado essa versão, dizendo, em juízo, que iriam comprar drogas, mas que sequer chegaram a realizar a compra.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumento de pena e está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que os Réus são primários, de bons antecedentes (fls. 38/46), não se dedicam a atividades criminosas e não integram organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

Reú GEOVANE

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 43/46).

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável e uma desfavorável, que se compensam, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), eis que a confissão em delegacia foi fundamento para a condenação. Como a pena base já foi fixada no mínimo legal, é impossível redução da pena abaixo desse limite nesta fase da dosimetria, ficando a pena base mantida como pena provisória.

Conforme exposto acima, não há causa de aumento de pena e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Assim, de rigor a redução da pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ré ALICE

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra a Ré, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas crack e cocaína, drogas especialmente viciantes e danosas à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. A Ré ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processada criminalmente anteriormente (fls. 38/42). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável e uma desfavorável, que se compensam, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes. Presentes, porém, as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), eis que a confissão em delegacia foi fundamento da condenação. Tendo a pena base já sido fixada no mínimo legal e vedada a redução da pena abaixo desse limite nessa fase, fica a pena base mantida como pena provisória.

Conforme exposto acima, não há causa de aumento de pena e há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Assim, de rigor a redução da pena provisória em 2/3, restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar os Réus ALICE

MOTA e GEOVANE DA SILVA MOREIRA como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, ambos às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, que deve ser encaminhado ao FUNAD.

Inalteradas as circunstâncias fáticas e considerando as penas em concreto aplicadas, concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade.

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intmem-se os Réus para o recolhimento das penas de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, em proporção, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA